

0004615-21.2017.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO
Comarca: Bebedouro
Foro: Foro de Bebedouro
Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... certeza. Contudo, como a casa é conhecida por tráfico, tal versão não pareceu verdadeira. As denúncias que aportam na polícia é de que a casa de Kely e Danilo é ponto de tráfico, assim como a casa da frente, de um tal de Alan. Já conhecia os acusados. Participou da prisão do marido de Kely, certo tempo atrás, no mesmo local, por tráfico. E Danilo sempre era visto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro - SP - cep 14706-136

0004615-21.2017.8.26.0072 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004615-21.2017.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELY YONE DOS SANTOS

CONCLUSÃO:

Nesta data faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. João Carlos Saud Abdala Filho, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Judicial desta Comarca. Bebedouro/SP, 18 de março de 2022. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M. 366.165.

Juiz de Direito: Dr. JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO.

Vistos.

Inicialmente, consigna-se que no processo nº 0009460-67.2015.8.26.0072 foi determinado o desmembramento dos autos, prosseguindo-se neste processo somente em relação à corré.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de DANILO ANTONIO DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e KELY YONE DOS SANTOS, já qualificada nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 183, caput, da Lei nº 9.472/1997.

Narra a denúncia que, no dia 26/11/2015, por volta das 12hs, no local indicado na inicial acusatória, o acusado Danilo possuía arma de fogo com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, um revólver Smith & Wesson, calibre 32, cromado.

Narra também que, nas mesmas circunstâncias de dia, hora e local, a acusada Kely

desenvolveu clandestinamente atividades de telecomunicação.

Os acusados foram presos em flagrante, mas a acusada Kely pagou a fiança arbitrada e foi solta (fls. 4/5 e 22). Conforme decisão de fls. 101/102, a prisão em flagrante do acusado Danilo foi convertida em preventiva.

A denúncia foi recebida no dia 10/12/2015, quando também foi concedido ao acusado Danilo o benefício da liberdade provisória (fls. 136/137). Alvará de soltura cumprido (fls. 154/157).

Os acusados foram citados (fls. 161 e 163) e apresentaram resposta à acusação (fls. 165/168 e 169/172). Manifestação do M.P. (fl. 178).

Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, para o dia 09/06/2016 (fl. 183).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada no dia 09/06/2016, se procedeu à inquirição de uma testemunha de acusação e foi designada audiência de continuação para o dia 06/10/2016 (fls. 209/210).

Já em audiência de continuação da instrução, debates e julgamento, realizada no dia 06/10/2016, se procedeu à inquirição da outra testemunha de acusação, da testemunha de defesa e ao interrogatório dos acusados, foi encerrada a instrução e foi concedido prazo para apresentação de memoriais (fls. 222/223).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência do pedido, com a condenação do acusado Danilo, nos termos da denúncia, e a absolvição da acusada Kely, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 229/236). A Defesa, por sua vez, em relação ao acusado Danilo, requereu a absolvição e, subsidiariamente, os benefícios no tocante à pena e ao regime (fls. 237/239). Já em relação à acusada Kely, a Defesa requereu a absolvição (fls. 240/241).

Foi proferida sentença em 26/06/2016 (fls. 251/262), que julgou procedente a denúncia em relação ao acusado Danilo e em relação à acusada Kely foi determinado: "Em relação à acusada KELY YONE DOS SANTOS, após o preclusa a presente decisão, por entender que a competência dos Juizados Especiais Criminais não é de natureza absoluta, determino que seja dada vista dos autos ao Ministério Público para que analise a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo em favor dela".

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público (certidão de fl. 320).

Nos termos do despacho de fl. 335, foi determinado o desmembramento dos autos em relação à acusada Kelly, que foi cumprido, gerando o presente processo (fls. 349 e 351). A sentença transitou em julgado para a acusada Kelly (certidão de fl. 358). O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo (fls. 362 e 376). Em audiência preliminar realizada no dia 19/03/2019, a acusada e a defensora aceitaram a proposta, sendo então homologado o acordo e suspenso o processo (fls. 403/404). Posteriormente, em razão do descumprimento das condições impostas, o Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo (fl. 427).

Nos termos da decisão de fls. 428/429, o benefício revogado em 19/08/2021 (fls. 428/429) e a acusada foi intimada (fl. 441).

Conforme decisão de fls. 457/458, o processo foi anulado a partir da determinação para apresentação de nova resposta à acusação, sendo determinado o andamento a partir da revogação do benefício concedido e, assim, foi declarada encerrada a instrução e concedido prazo para apresentação de memoriais.

Em memoriais, a Defesa requereu a absolvição da acusada, nos termos do art. 396, inciso VII, do CPP, e, subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da insignificância, com a absolvição da acusada nos termos do art. 386, inciso III, do CPP (fls. 459/464). Já o Ministério Público requereu, preliminarmente, a emendatio libeli, nos termos do art. 383 do CPP, e no mérito requereu a condenação da acusada, como incurso no art. 70 da Lei nº 4.117/1962 (fls. 468/475).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A acusação é procedente em parte.

Preliminarmente, conforme ponderado pelo Ministério Público, é caso de reparo no

que tange à imputação deduzida em face da acusada, por meio do instituto da emendatio libelli, na forma do art. 383 do CPP, já que consta da inicial acusatória a correta descrição dos fatos, porém, há equívoco na tipificação, o que inclusive já foi feito na r. sentença proferida nos autos desmembrados (fls. 251/262), cuja fundamentação reitero, destacando os seguintes trechos:

“Com efeito, conforme acima relatado, a inicial acusatória não narra o caráter habitual do exercício clandestino da atividade de telecomunicações pela acusada Kely. Nesse tanto, limita-se a afirmar que, em uma oportunidade isolada, fora apreendido rádio comunicador que estava sob a posse dela, ligado na mesma frequência utilizada pela Polícia Militar.

Como se vê, a conduta narrada na denúncia não se amolda ao tipo descrito pelo art. 183 da Lei 9472 de 1997, pois não contém descrição da circunstância relativa à habitualidade, motivo pelo qual dou a ela nova capitulação jurídica, para que passe a ser analisada como o crime descrito pelo art. 70 da Lei 4.117 de 1962”.

Portanto, os fatos narrados na denúncia amoldam-se ao tipo descrito pelo art. 70 da Lei nº 4.117/1962.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 4/10, boletim de ocorrência de fls. 12/15, o auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo pericial de fls. 56/59, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial.

Quanto à autoria, necessária análise mais detida.

O policial militar Dalton, em juízo, relatou que “foi até o bairro, especificamente aquela casa, é conhecida por traficância. Assim, foi patrulhar em vistas a coibir o tráfico. Viram Kely defronte à residência e ela correu para dentro de casa. Foram atrás dela e ela estava deitada, fingindo estar dormindo. Embaixo da cama, havia um HT na frequência da polícia. Há notícias, na corporação, de que naquele bairro os traficantes se utilizam de rádios HTs para copiarem a frequência da polícia e assim saberem, de antemão, sobre alguma denúncia de tráfico e respectiva ação policial, de modo que quando a polícia ia ao bairro o agente criminoso sempre já havia se dissipado. O rádio estava debaixo do colchão, entre o estrado e o colchão. Ele estava ligado na frequência da polícia militar. O próprio depoente podia ouvir aquilo que dizia no rádio, via COPOM. Ao entrar no ambiente do quarto, pediu para a ré se levantar da cama e por costume verificou debaixo do colchão, encontrando o rádio ligado. Na casa, moravam Kely, a sogra dela e o corréu Danilo. O quarto onde foi encontrado o rádio era de Kely, segundo ela própria. No quarto havia somente uma cama, na qual o objeto foi encontrado. Sobre o rádio, não se recorda as alegações da ré. A casa foi vistoriada e em um dos quartos, de Danilo, foi encontrado um revólver entre as roupas. Danilo negou ser proprietário da arma, porém, segundo ele o quarto era dele. Havia roupas masculinas no quarto, o qual possuía duas camas de solteiro. Além disso, encontrou-se dinheiro, embrulhado em uma fita marrom, bem compactado, e após a contagem era mais de R\$5.000,00 em notas miúdas. Não se recorda qual dos dois réus, contudo disseram que o dinheiro era doação de um pastor da igreja à mãe de Danilo, mas não tem certeza. Contudo, como a casa é conhecida por tráfico, tal versão não pareceu verdadeira. As denúncias que aportam na polícia é de que a casa de Kely e Danilo é ponto de tráfico, assim como a casa da frente, de um tal de Alan. Já conhecia os acusados. Participou da prisão do marido de Kely, certo tempo atrás, no mesmo local, por tráfico. E Danilo sempre era visto no local. Os réus sempre ficam na rua, não são vistos trabalhando. Quando a polícia passa, sempre estão por ali. No momento da diligência, recorda-se de haver duas ou três crianças na casa. Adultos não. Danilo já estava no interior da casa quando a polícia entrou”. Indagado pelo Promotor de Justiça o depoente respondeu que “entrou na frente, o PM Nilmar ficou com Danilo na sala. No quarto de Danilo, também encontrou a arma. Posteriormente, o PM Nilmar foi ao quarto e encontrou o dinheiro”.

O policial militar Nilmar, em juízo, relatou que “estava em patrulhamento. Já havia denúncia de tráfico no local dos fatos. Em patrulhamento, viram a ré correndo para o imóvel, após ver a polícia. Entraram na casa e a ré estava deitada, fingindo dormir. Quando Dalton entrou no quarto, encontrou o rádio HT na frequência da

polícia, embaixo do colchão dela. Dalton ainda encontrou o réu e no quarto dele o revólver. Um casaco do réu foi encontrado no quarto da mãe dele, sendo que no bolso havia o dinheiro. O réu assumiu a propriedade do casaco, mas não do dinheiro. Os acusados não esclareceram a origem do dinheiro. O rádio HT encontrado no quarto da ré estava ligado e sintonizado na frequência da polícia. O PM Dalton chegou a testar uma chamada ao COPOM e o sinal foi reproduzido no rádio. Não conhecia os acusados. As denúncias eram de que no imóvel ocorria tráfico. Esta rua é a principal de tráfico do bairro Santa Terezinha. O quarto onde o rádio HT foi encontrado tinha uma cama de solteiro e a ré estava deitada na cama. O quarto onde estava o revólver, Danilo admitiu ser dele”.

A testemunha de defesa Eliana, em juízo, disse que “é ex-sogra da ré. É mãe do Danilo. A casa onde foi feita a batida policial é da depoente. Não estava em casa no dia dos fatos. Quando chegou em casa, soube que Danilo fora preso, que fora encontrada uma arma e que a polícia levava o dinheiro que a depoente guardava dentro do guarda-roupa, dinheiro este que Danilo tinha recebido de indenização por dispensa de trabalho. O dinheiro era de Danilo e estava sendo guardado pela depoente a pedido dele. Na época Kely morava na residência. Soube de um rádio HT apreendido na residência. Tal rádio foi encontrado pelas crianças no quintal, mas não sabe onde a polícia o achou no dia”. Indagada pela Defensora a depoente respondeu que “a casa da depoente não tem segurança, qualquer um entra. O dinheiro era para a reforma da casa, por isso alegou que o dinheiro era do padre”.

Ao ser interrogado em juízo o acusado Danilo afirmou que “tem 28 anos. É eletricitista industrial. Quando foi preso tinha acabado de sair de uma firma. Ganhava uma base de R\$1.900,00 com horas extras. Estudou até 8º ano completo. Tem dois filhos e é amasiado. É usuário de cocaína. Está preso por tráfico e associação, faz um mês e uns dias. Não tem condenação ainda. A respeito do revólver, não sabia da existência da arma. O quarto onde estava a arma era do interrogando. A casa era aberta, não tinha portão e porta. Não sabia da existência da arma. Sobre o HT, ele foi encontrado no quintal, até mesmo achou que a ré tinha jogado fora, mas depois a polícia encontrou no quarto dela. O dinheiro era o acerto do interrogando e foi entregue à mãe para ela guardar. Direto fica pedindo dinheiro à mãe e ela lhe disse que o dinheiro era do padre, para construir a casa. Era uma forma de ela preservar o dinheiro e não entregar ao interrogando que iria gastá-lo”.

Ao ser interrogada em juízo a acusada Kely afirmou que “tem 23 anos. Estudou até sexta série. Tem uma filha. Solteira. É manicure, aufera R\$600,00 por mês. Nunca foi processada. Sobre o rádio HT, estava deitada em seu quarto e o policial achou o rádio debaixo da cama. O rádio tinha sido achado pelas crianças e a interroganda o guardou debaixo da cama. O rádio estava desligado e foi ligado pelo policial Dalton. Saiu do quarto enquanto os policiais fizeram a revista. A arma que estava no quarto do cunhado não sabe de quem era. Não sabe para que o rádio servia. Fazia uma semana que as crianças tinham achado o rádio HT, o guardou para ver o que faria depois. Não sabe mexer no rádio e nega saber que estava sintonizado na frequência da polícia”.

Eis o extrato da prova oral produzida nos autos.

Com efeito, a prática do crime em questão pela acusada restou devidamente comprovada.

Dispõe o art. 70 da Lei nº 4.117/1962: “Art. 70. Constitui crime punível com a pena de detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, a instalação ou utilização de telecomunicações, sem observância do disposto nesta Lei e nos regulamentos”.

No caso, os policiais militares ouvidos foram firmes e coesos no sentido de que o rádio HT foi encontrado no quarto da acusada, estava ligado e sintonizado na frequência da polícia.

O laudo pericial de fls. 56/59 também atestou que o rádio HT estava operando a

contento e na frequência da polícia militar.

Por sua vez, a versão da acusada, "de que o rádio tinha sido achado pelas crianças", restou inverossímil, não sendo corroborada por qualquer outro elemento de prova, afinal, apenas a testemunha de defesa disse saber de tal alegação, mas ela é genitora do corréu, o que certamente interfere no interesse em proteger os acusados.

Frise-se que a jurisprudência é firme no sentido de que a configuração do tipo penal em apreço não reclama a prática habitual da conduta tipificada, bastando que a conduta descrita no dispositivo legal seja praticada uma única vez.

Nesse sentido, cita-se:

"HABEAS CORPUS. ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÕES CONTRA O DISPOSTO EM LEI. TIPIFICAÇÃO DA CONDUCTA. ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DA CONDUCTA. INCIDÊNCIA DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. ORDEM DENEGADA. 1. A diferença entre a conduta tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações e a do art. 183 da nova lei de Telecomunicações está na habitualidade da conduta. 2. Quando a atividade clandestina de telecomunicações é desenvolvida de modo habitual, a conduta tipifica o disposto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, e não o art. 70 da Lei nº 4.117/62, que se restringe àquele que instala ou utiliza sem habitualidade a atividade ilícita em questão. 3. A denúncia narrou o uso ilegal das telecomunicações de modo habitual pelo réu, sendo correta a tipificação que lhe foi dada. 4. Ordem denegada" (HC 93870, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-168 DIVULG 09-09-2010 PUBLIC 10-09-2010 EMENT VOL-02414-02 PP-00339 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 483-486).

Deste modo, configurado o crime previsto no art. 70 da Lei nº 4.117/1962, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes e nem atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Portanto, fixo a pena em 1 (um) ano de detenção.

Tendo em vista a quantidade de pena e por ser a acusada tecnicamente primária, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor da fiança paga (fl. 22 - R\$ 1.000,000 e os acréscimos legais), em favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente desta Comarca.

Uma vez fixado o regime inicial aberto, não há que se falar na possibilidade de aplicação da detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPP.

Não há pedido de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.

Ante a todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR a acusada KELY YONE DOS SANTOS, como incurso no crime descrito pelo artigo 70 da Lei nº 4.117/1962, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor da fiança paga (fl. 22 - R\$ 1.000,000 e os acréscimos legais), em favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente desta Comarca.

A acusada respondeu a todo o processo em liberdade e não há nada que indique a necessidade de decretação de prisão preventiva. Assim sendo, concedo a ela o direito de recorrer em liberdade por este processo.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro à acusada os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Fixo os honorários do Defensor dativo (fl. 443) no máximo do respectivo item da

tabela do convênio OAB/Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe.

Após o trânsito em julgado:

O valor da fiança (fl. 22 - R\$ 1.000,000 e os acréscimos legais) deverá ser utilizado para pagamento da prestação pecuniária.

Determino a destruição do rádio HT apreendido e periciado (fls. 16/17, 56/59, 321 e 334).

Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva.

Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P. I. C.

Bebedouro/SP, 05/05/2022.

JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA